

1500630-39.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... as substâncias eram destinadas ao tráfico ilícito. Requereu-se, ao final, a decretação do perdimento definitivo dos valores apreendidos, porquanto produto do narcotráfico.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), auto de constatação preliminar de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500630-39.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500630-39.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115870/2021 - 01º D.P.

PINDAMONHANGABA, 17606201 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 682/21/412 - 01º D.P.

PINDAMONHANGABA, 2115870 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA ("RAFAEL") e DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS DOMINGUES ("DOUGLAS"), ambos qualificados nos autos em epígrafe, foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 35, "caput", e 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, observando-se as disposições da Lei nº 8.072/90. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 1/4), a partir de data incerta e até o dia 28 de abril de 2021, neste Município e Comarca, os acusados se associaram para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Emerge, ainda, que, no dia 28 de abril de 2021, por volta das 15h00, na Rua Josias Pereira, em frente ao nº 22, Jardim Resende, neste Município, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de propósito entre si, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com peso bruto total de 66,01g, bem como 52 (cinquenta e duas) porções e um pedaço de "tijolo" de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como "maconha", contendo tetraidrocanabinol, com peso bruto total de 523,4g, drogas aptas a causarem dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, RAFAEL e DOUGLAS se associaram com a finalidade de traficar drogas nesta Comarca, especialmente para a guarda, depósito, venda e

entrega a consumo de terceiros de cocaína e de “maconha”; os réus adquiriam as drogas, em geral grande quantidade; guardavam e mantinham em depósito aquelas substâncias; e vendiam as drogas aos consumidores. Apurou-se, ainda, que, no dia 28 de abril de 2021, no local acima mencionado, os réus, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, guardam, tinham depósito e traziam consigo as porções de drogas acima mencionadas, já embaladas individualmente – as de cocaína, em tubos plásticos do tipo “eppendorf”; as de “maconha”, em sacos plásticos, além de meio “tijolo” de maconha, que seria posteriormente fracionado para venda no varejo. Consta da denúncia que, em razão de informações de que ocorria tráfico no local, os policiais militares rumaram para lá, sendo que, RAFAEL e DOUGLAS, ao notarem a chegada dos agentes, arremessaram as sacolas contendo as drogas sobre o telhado e tentaram se esconder no interior da residência, mas foram detidos, tendo os policiais encontrado as drogas nas sacolas arremessadas e, em poder de DOUGLAS, o valor de R\$40,00 (quarenta reais), obtidos com a venda de outras porções de drogas. Extraí-se, também, da denúncia, que em razão da quantidade da droga apreendida, a diversidade de espécies, a forma de embalagem e de condicionamento, restou evidenciado que as substâncias eram destinadas ao tráfico ilícito. Requereu-se, ao final, a decretação do perdimento definitivo dos valores apreendidos, porquanto produto do narcotráfico.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 24/25), imagens das drogas e valores apreendidos (fls. 29/32 e 34), relatório final de inquérito policial (fls. 70/71), comprovante de depósito judicial do dinheiro apreendido (fl. 85) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 93/94).

O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 49/54).

Dispensada a realização de audiência de custódia em razão do sistema remoto de trabalho em primeiro grau, foi concedida liberdade provisória aos réus, cumulada com medida cautelar de comparecimento mensal em juízo (fls. 58/59).

Por decisão de fls. 74/75, foram isentos da condição de comparecimentos periódicos, devendo manter seus endereços atualizados e comparecerem em juízo sempre que intimados; ainda, para evitar eventual alegação de nulidade, em razão do momento processual de recebimento da denúncia sem prévia apresentação de defesa pelos acusados, foi diferido o recebimento da denúncia para o momento processual previsto no artigo 399, do Código de Processo Penal,

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 105/108).

Regularmente citados (fls. 81 e 83), os réus, por meio de sua defensora nomeada (fl. 90), ofertaram resposta à acusação a fls. 96/97.

Não alegadas preliminares nem vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 105/108 e 129/130).

Na audiência designada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado, declarando-se o encerramento da instrução; o Ministério Público apresentou alegações finais orais, tendo requerido a parcial procedência da ação, com absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e condenação em relação ao delito de tráfico de entorpecentes (fls. 147/148).

Ao seu turno, a defesa técnica dos acusados, em alegações finais apresentadas por escrito a fls. 149/159, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da prova colhida nos autos em virtude de vício decorrente da invasão de domicílio. Requereu a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, pugnando pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, tendo, subsidiariamente, em caso de condenação, pugnado pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11343/06, com atribuição do regime aberto para início de cumprimento de pena e concessão do direito de os réus apelarem em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De saída, fica afastada a tese de ilicitude da prova decorrente de diligência

policial na residência onde encontradas as drogas.

O crime de tráfico atribuído aos réus tem natureza permanente, existindo, portanto, exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

Ora, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso em residência na hipótese de flagrante delito, sendo desnecessário o mandado judicial de busca.

A propósito, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

1. O paciente foi acusado da prática de delitos de natureza permanente, quais sejam, tráfico de entorpecentes e receptação na modalidade 'ocultar'. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina e jurisprudência. 3. Ordem denegada (HC 188195/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, j. em 27.09.2011, DJU de 28.10.2011).

Ainda daquela Corte Superior, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina e jurisprudência (HC 223715/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, j. em 02.02.2012, DJU de 15.02.2012).

Mais: tratando-se de crime permanente torna-se despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local (STJ, HC nº 233.302/SP, relator o min. Gilson Dipp, DJU de 20.06.2012).

Não dissonante, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (tema 280), no sentido de que: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE 603616/RO, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Plenário, m.v., j. 05/11/2015).

Júlio Fabbrini Mirabete ensina que ("Código de Processo Penal Interpretado", ed. 2006, pg. 753, em comentário ao art. 303 - "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência"): o dispositivo, que permite a prisão em flagrante no crime permanente enquanto não cessar a permanência é, teoricamente, supérfluo, uma vez que nessa espécie de crime a consumação se prolonga no tempo, dependendo da conduta do agente.

E conclui Mirabete: tratando-se de situação de flagrância nessas hipóteses, é evidentemente dispensável, mesmo durante a noite, que o autor da prisão porte mandado judicial para invadir a casa onde o crime está sendo praticado.

Dessa compreensão não destoa o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo em que a prevê, como no caso de flagrante delito. Crime imputado que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou mesmo de autorização do residente no imóvel. Situação de flagrância confirmada, a legitimar o ingresso. Preliminar afastada. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam a ré guardando e mantendo em depósito um tijolo de maconha, com massa líquida de 420,210g, 12 eppendorf contendo 3,460g de "cocaína", um cigarro artesanal de "maconha", pesando 1,450g e 8 invólucros plásticos sólidos de "cocaína", pesando 1,140g, mais R\$ 232,80 em dinheiro, após visualizá-la em movimentação típica de tráfico com indivíduo não identificado, em local conhecido como ponto de tráfico. Acusada confessou, em ambas as fases da persecução penal, seu envolvimento com o comércio espúrio. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida. PENAS. Pena base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida, e os maus antecedentes. Redução do percentual para 1/5, mais proporcional. Na segunda fase,

correto o reconhecimento da reincidência específica, da origem, que é nesta instância compensada com a confissão espontânea, haja vista que a ré admitiu a traficância, em ambas as fases da persecução penal. Incabível o redutor na terceira fase, por expressa vedação legal aos reincidentes e de maus antecedentes. REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade da pena corporal aplicada, os maus antecedentes e a reincidência específica da acusada e, ainda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo parcialmente provido, para redimensionar as penas impostas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa mínimos,, mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP; Apelação Criminal 1502386-56.2021.8.26.0530; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022 - ênfase aposta).

Saliente-se que havia fundada suspeita sobre a prática do tráfico na residência, em razão da existência de denúncias (fls. 33), da fuga dos envolvidos para dentro da casa ao avistarem os policiais e da visualização pelos agentes públicos dos acusados jogando sacolas em cima do telhado, o que levou, de fato, à localização de 37 (trinta e sete) porções de cocaína e do valor de R\$40,00 (quarenta reais) em pecúnia, além de mais 52 (cinquenta e duas) porções e um pedaço de "tijolo" de maconha.

Daí, ressalvado o denodo da ilustrada Defesa, não se poder falar de nulidade da prova.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente, condenando-se os réus pelo crime de tráfico e absolvendo-os em relação ao crime de associação para o tráfico. Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 24/25), imagens das drogas e valores apreendidos (fls. 29/32 e 34), relatório final de inquérito policial (fls. 70/71), comprovante de depósito judicial do dinheiro apreendido (fl. 85) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo positivo para o princípio ativo das drogas examinadas (fls. 93/94).

No que tange à autoria dos acusados RAFAEL e DOUGLAS, restou indubitosa em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, entretanto não restou comprovada em relação ao crime de associação para o tráfico.

Com efeito, perante a autoridade policial (fls. 7/8), a testemunha JEFFERSON SANTOS DE PAULA, policial militar, relatou in verbis que: (...) na data de hoje, 28 de abril de 2021, por volta das 15h00min, diligenciaram até o bairro Jardim Resende com objetivo de averiguar denúncia por tráfico de drogas. Questionado, afirma que a denúncia foi passada pelo serviço reservado da Polícia Militar; afirma também que o local já fora informado por outros moradores durante diligências no bairro.

Deslocaram-se até a rua Josias Pereira, nº 22, Jardim Resende, Pindamonhangaba.

Logo que entraram na rua avistaram dois sujeitos do sexo masculino na porta de residência alvo da denúncia. Realizaram aproximação, momento em que ambos correram para dentro do portão, precisamente no corredor. Neste momento foi possível visualizar que sacolas foram jogadas no telhado. Cercaram a casa e chamaram os sujeitos, afirmando que a casa estava cercada e não adiantava tentar fugir. Os sujeitos saíram no portão, momento em que foram identificados, um como sendo RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA e outro como DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS DOMINGUES, ambos maiores de idade. Foram informados das denúncias, bem como que haviam visualizado que sacolas foram jogadas no telhado. Neste momento ambos reconheceram que havia drogas nas sacolas, mas informaram que era para consumo próprio. RAFAEL disse que havia jogado uma sacola com maconha, ao passo que DOUGLAS afirmou que havia jogado uma sacola com pinos de cocaína; afirmaram que haviam comprado as drogas em conjunto para consumirem. As sacolas foram arrecadadas; em uma havia a quantia de

52 porções menores de maconha mais metade de um tijolo da mesma droga; na outra havia 37 pinos de cocaína. Afirma, ainda, que em revista pessoal localizou a quantia de R\$40,00 com a pessoa de DOUGLAS. Diante do fatos foi dado voz de prisão para ambos, sendo conduzidos até a Delegacia de Polícia para o tramites legais. Inquirido sob o crivo do contraditório, o policial militar JEFFERSON SANTOS DE PAULA confirmou as particularidades da diligência, afirmando que, estando de serviço na data dos fatos, receberam uma denúncia de um morador que relatou o tráfico de drogas na residência de RAFAEL, local alvo de diversas denúncias, ao que se dirigiram para lá; quando chegaram, viram os dois réus no portão, os quais, ao visualizarem a viatura, encostaram o portão e correram para dentro da residência, ocasião em que a equipe visualizou, pelo vão do portão, os acusados jogando sacolas em cima do telhado; após a informação de que estariam cercados, os réus foram até o portão, sendo que, em busca pessoal, foi apenas encontrada a quantia de R\$40,00 (quarenta reais) com DOUGLAS. Asseverou que, indagados a respeito da denúncia e das sacolas arremessadas, os acusados admitiram que cada um deles havia jogado uma sacola com drogas no telhado; RAFAEL informou que na sua sacola havia maconha, tendo DOUGLAS dito que na sacola dele havia pinos de cocaína e ambos afirmado que compraram a droga juntos e que seria para consumo deles. Assinalou que os réus franquearam a entrada os agentes na residência; foram localizadas as duas sacolas em cima do telhado, sendo que, em uma delas havia 52 (cinquenta e duas) porções de maconha e mais meio tijolo de maconha, havendo, na outra sacola, 37 (trinta e sete) pinos de cocaína. Disse que RAFAEL já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico, utilizando-se do mesmo modus operandi, realizando a venda dos entorpecentes na porta de sua residência, continuando ele até hoje no tráfico, embora tenha se mudado para outro bairro; não se recorda se algum dos acusados estava com o braço enfaixado. Em atendimento às reperguntas da acusação, afirmou que, frequentemente, via os acusados juntos naquele bairro, tendo havido muitas denúncias de prática de tráfico por ambos os réus pelo Disk Denúncia, tendo, na data dos fatos, o COPOM irradiado a denúncia de traficância pelos réus. Às reperguntas da defesa, questionado sobre a fachada da residência de RAFAEL, informou que o portão possuía dois vãos laterais, por onde foi possível visualizarem os réus correndo e arremessando drogas para o telhado. Ao final, esclareceu que RAFAEL autorizou a entrada na residência para vistoria e localização das sacolas que admitiu ter arremessado (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3NXurUj>, referido à fl. 148, ênfase apostas).

De forma uníssona, o também policial militar JOÃO GABRIEL ARNEIRO GUIMARÃES RODRIGUES relatou a mesma dinâmica dos fatos ao ser ouvido na fase policial (fl. 9), tendo em juízo informado que, na data dos fatos, receberam denúncia de tráfico em um local que já era alvo de várias reclamações de moradores do bairro, havendo, inclusive, denúncias recebida por ligações ao 181, tendo se deslocado para lá; quando chegaram, viram os dois réus no portão, os quais, ao visualizarem a viatura, evadiram-se para dentro da residência, ocasião em que a equipe visualizou os acusados jogando sacolas em cima do telhado; após a informação de que estariam cercados, os réus foram até o portão, sendo que, em busca pessoal foi apenas encontrada a quantia de R\$40,00 (quarenta reais) com DOUGLAS. Asseverou que, indagados a respeito da denúncia e das sacolas arremessadas, os acusados confessaram que cada um deles havia jogado uma sacola com drogas no telhado; RAFAEL informou que na sacola dele havia maconha, tendo DOUGLAS dito que na sacola dele havia pinos de cocaína, tendo ambos afirmado que compraram a droga juntos e que seria para consumo deles. Assinalou que RAFAEL franqueou a entrada os agentes na residência; foram localizadas as duas sacolas em cima do telhado, sendo que, em uma delas havia 52 (cinquenta e duas) porções e mais meio de tijolo de maconha, havendo, na outra sacola, 37 (trinta e sete) pinos de cocaína. Disse que RAFAEL já era conhecido dos meios policiais há mais de cinco anos pela prática de tráfico, utilizando-se do mesmo modus operandi, com venda de entorpecentes na porta de sua residência, embora tenha se mudado para outros bairros; não se recorda se algum dos acusados estava com o braço enfaixado. Em atendimento às reperguntas da acusação, asseverou que, frequentemente, via os acusados juntos no Bairro Vila Rica, tendo

havido muitas denúncias da prática de tráfico por ambos os réus, tendo, na data dos fatos, o COPOM irradiado a denúncia de traficância. Às reperguntas da defesa, questionado sobre a fachada da residência de RAFAEL, informou que o portão era confeccionado em chapa, havendo vãos laterais para a abertura; acrescentou que os réus confirmaram que havia drogas nas sacolas arremessadas para o telhado (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3NXurUj>, referido à fl. 148, ênfase aposta).

Já a testemunha JÉSSICA DE SOUZA, esposa de RAFAEL, ouvida somente em juízo, disse que, embora RAFAEL tenha traficado drogas anteriormente, na data dos fatos já havia cessado com a atividade delitiva. Informou que a droga apreendida na data dos fatos se destinava ao consumo dos réus em uma festa. Disse que RAFAEL comprou 375g de maconha em Aparecida, sendo que DOUGLAS estava com 12 (doze) pinos. Asseverou que os dois acusados arremessaram a sacola com os entorpecentes para cima do telhado porque viram a polícia chegando; que RAFAEL consome muita droga. Em atenção às reperguntas da defesa, contou que RAFAEL fuma uma quantidade de 25g de maconha em três dias. Em atendimento às reperguntas da acusação, respondeu que a droga foi adquirida, por, aproximadamente, R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais) (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3NXurUj>, referido à fl. 148, ênfase aposta).

A seu turno, o corréu RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA, perante a autoridade policial (fls. 10/11), contou in verbis que: (...) nesta data estava no interior de sua residência quando percebeu a presença das motocicletas da polícia militar e como tinha consigo "um carço" de maconha, jogou por cima do muro; DOUGLAS trazia consigo 12 pinos de cocaína os quais o interrogado pegou das mãos de DOUGLAS e também os jogou por cima do muro, isto porque DOUGLAS encontra-se com o braço quebrado e engessado; logo em seguida quando os policiais militares ali chegaram mandando que abrisse o portão e este lhe informou ter visto quando jogou o entorpecente sobre o muro, oportunidade em que o interrogado disse que "o carço era seu, umas 375 gramas de maconha" mas que os pinos eram de DOUGLAS, o qual imediatamente confirmou a versão do interrogado aos policiais; foi-lhe dada voz de prisão e conduzido até a delegacia; não tem passagem criminal; informa faz uso de maconha e cocaína e que a maconha e cocaína eram para seu uso pessoal e de DOUGLAS, a qual adquiriu no município de aparecida, de pessoa desconhecida que encontrou na rua, próximo das barracas de comercio ambulante, tendo pago pela mesma a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Em seu interrogatório judicial, o réu RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA disse ter ido com DOUGLAS comprar as drogas em Aparecida, para poderem utilizá-las em uma festa; na data dos fatos; os policiais chegaram e foram abrindo o portão, momento em que arremessou as drogas para o telhado. Disse conhecer o policial Arneiro e outros policiais. Contou que Douglas estava com o braço machucado. Informou que, no momento da abordagem, disse aos policiais que havia um "negocinho" para usar, tendo sido apreendidos somente 375g de maconha e 12 (doze) pinos de cocaína que os réus haviam comprado para consumo. Disse que na Delegacia havia muito mais drogas, o que teria sido forjado pelos policiais, os quais sempre o perseguem. Em atendimento às reperguntas da acusação, afirmou que fuma maconha todos os dias. Informou que a porção de maconha custou R\$ 200,00 (duzentos reais) e a de cocaína R\$ 120,00 (cento e vinte reais). Às reperguntas da defesa, informou que a fachada da sua casa é toda fechada, com portão de chapa e existência de um vão para o cadeado, não sendo possível visualizar o interior da casa. Disse que estavam dentro da casa. Afirmou que não foi dada a autorização para os policiais entrarem na residência. Asseverou que as sacolas contendo as drogas foram arremessadas para o telhado antes de os policiais ingressarem na residência; admitiu que os policiais os viram jogando as sacolas (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3NXurUj>, referido à fl. 148, ênfase aposta).

Por sua vez, perante a autoridade policial (fls. 12/13), o corréu DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS DOMINGUES declarou in verbis que: (...) nesta data estava no interior de sua residência, juntamente com RAFAEL sentados no quintal, quando percebeu a presença das motocicletas da polícia militar e como RAFAEL tinha consigo "um carço" de maconha, e o interrogado tinha 12 pinos, RAFAEL pegou todos os

entorpecentes e jogou por cima do muro, isto porque encontrava-se com o braço quebrado e engessado; logo em seguida quando os policiais militares ali chegaram mandando que abrisse o portão e este lhe informou ter visto quando jogou o entorpecente sobre o muro, oportunidade em que o interrogado disse que "os 12 pinos eram seus e a maconha era seu, umas 375 gramas de maconha" sendo que RAFAEL imediatamente confirmou a versão do interrogado aos policiais; foi-lhe dada voz de prisão e conduzido até a delegacia; não tem passagem criminal; informa fazer uso de maconha e cocaína e que a maconha e cocaína eram para seu uso pessoal e de RAFAEL, a qual adquiriram no município de Aparecida/SP, de pessoa desconhecida que encontrou na rua, próximo das barracas de comércio ambulante, tendo pago pela mesma a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Em seu interrogatório judicial, o réu DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS DOMINGUES destacou que, dias antes, adquiriram um "caroço" de maconha e 12 (doze) pinos de cocaína em Aparecida, pois iriam usar juntos em uma festa; que, quando os policiais passaram na rua, assustaram-se, tendo pedido a RAFAEL que jogasse os entorpecentes em cima do telhado; afirmou que os policiais invadiram a residência. Questionado se as drogas encontradas pelos policiais estavam dentro das sacolas, disse que havia um "caroço" de maconha fora da sacola, bem como 12 (doze) pinos com o interrogando, tendo passado para RAFAEL arremessá-las, pois estava com o braço quebrado, de forma que não havia nada nas sacolas. Questionado sobre o restante da droga apreendida, disse que somente havia 375g de maconha e 12 (doze) pinos de cocaína. Afirmou que os policiais teriam motivos para incriminar RAFAEL. As reperguntas da defesa, informou que a fachada da casa é toda fechada, havendo um portão confeccionado em chapa com um vão para o cadeado; no momento dos fatos estavam fazendo uso de entorpecentes dentro da casa, estando tudo fechado. Afirmou que não franqueou a entrada dos policiais na residência, não tendo eles apresentado mandado judicial. Asseverou que as drogas foram arremessadas para o telhado no momento em que os policiais pararam em frente à residência, bem como que não havia sacolas, tendo arremessado somente o "caroço" de maconha e os 12 (doze) pinos de cocaína (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3NXurUj>, referido à fl. 148, ênfase apostá). Pese a negativa dos réus sobre a finalidade mercantil das drogas, não há dúvidas da prática do tráfico pelos acusados.

Isso porque os policiais militares confirmaram que, em atendimento à ocorrência para averiguação de denúncia de tráfico na residência do acusado RAFAEL, os réus, quando avistaram a guarnição policial, evadiram-se para interior da casa, momento em que tentaram se desfazer de objetos, arremessando-os para o telhado. Os agentes públicos confirmaram, ainda, que, ao localizarem os objetos dispensados, constataram que se tratava de sacola contendo os estupefacientes.

A tipificação do crime, in casu, revela-se com plenitude a partir do local da apreensão, cuidando-se da residência do acusado RAFAEL, para a qual havia muitas denúncias de ocorrência de tráfico, e de suas circunstâncias, que envolveram tentativa de desfazimento dos entorpecentes pelos réus ao visualizarem os policiais, bem como da natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes, consistentes em 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, com peso bruto total de 66,0g, além de 52 (cinquenta e duas) porções e um pedaço de "maconha, com peso bruto de 523,4g (laudo químico-toxicológico positivo - fls. 24/25 e 93/95), assim como do modo como estavam acondicionados, em porções individuais, a facilitar sua comercialização e disseminação, conforme fotografias de fls. 29/32 e 34.

É de se consignar que, além das substâncias entorpecentes, foi apreendida a quantia de R\$40,00 (quarenta reais), sem origem devidamente esclarecida (fls. 24/23 e 85). Importante destacar que não há que se desmerecer os depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas tão só pelo fato de serem eles policiais. Tal significaria preconceito inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional, que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que a Defesa nada comprou contra a honradez e honorabilidade das testemunhas deste processo, nem mesmo que tivessem elas qualquer razão escusa para pretender prejudicar os réus, de forma que seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão

conforme o conjunto das provas e, ademais, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Doutro giro, sobreleva salientar que o depoimento da testemunha arrolada pela Defesa, tomado sem compromisso por se tratar da esposa do corréu RAFAEL, evidenciou-se fluído, frágil, naturalmente inquinado de suspeição e, portanto, sem força para influir no convencimento do julgador quando confrontado com o restante das provas.

No mais, considerando a natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas e demais circunstâncias já explicitadas, a alegação dos réus de que a droga serviria ao seu consumo não convence.

Não houve, portanto, comprovação de destinação exclusiva da droga ao uso próprio, pois nada impede que o usuário seja também traficante, inclusive para satisfazer o próprio vício, se afigurando inviável a desclassificação no caso concreto.

É importante assinalar que para a caracterização e consumação da conduta "guardar" ou "ter em depósito", prevista no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Basta, tão-somente, que o agente tenha em depósito a substância entorpecente para se ter por consumado o crime, pois o delito previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é de perigo à saúde pública. O perigo é presumido, configurando-se o crime quando a conduta do agente esteja contida em um dos verbos descritos no tipo penal, como restou evidente na hipótese vertente.

Nada obstante, no que se refere ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, não há provas suficientes que sustentem o édito condenatório.

Conforme ensina Vicente Greco Filho: Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria' (Lei de Drogas Anotada: Lei nº 11.343/2006. São Paulo: Saraiva 2006; p.120 - ênfase apostá).

Os dados probatórios colhidos não autorizam a conclusão sobre a existência de uma associação, com a qualificação exigida pela lei, entre os acusados, consoante argumentado pelo Parquet em sede de memoriais orais.

Nessa esteira, não restou comprovada a existência de associação duradoura e estável entre os acusados para a prática do tráfico, de forma que o vínculo associativo não se patenteou no caso em tela.

Devidamente caracterizado apenas o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), passo a individualizar as penas.

Réu RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não se identifica motivo válido para majoração da pena-base (fls. 119/120), que fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Faz-se necessário esclarecer que inquéritos e ações em andamento não podem ser levadas em consideração para majoração da pena (Súmula 444, STJ).

Na segunda fase, não concorrem agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento, contudo é de se aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06 porquanto, o acusado é tecnicamente primário, não registra maus antecedentes (fls. 119/120), bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminoso e se dedique a atividades ilícitas.

Quanto ao montante da diminuição, diante do silêncio da lei, serão adotadas as circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, de forma preponderante, além das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como forma de cumprir o princípio da individualização da pena, decorrente da isonomia, tratando-se de forma igual os iguais, e desigual os desiguais, na medida exata das desigualdades. Não obstante, com a finalidade de afastar a alegação de "bis in idem", conforme decisão também do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (HC 112776/MS), apenas aquelas circunstâncias

do artigo 42, da Lei Antidrogas, ou do artigo 59, do Código Penal, não utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena podem ser valoradas para obtenção do quanto de diminuição.

Considerando a prática do delito em concurso de agentes, bem como a variedade - duas espécies - quantidade e a natureza das drogas (66,01g de cocaína e 523,4g de maconha - fls. 22/23), uma delas - cocaína - de elevado poder vulnerante à saúde pública -, a denotar organização, ainda que incipiente, da atividade criminosa, inclusive referendada por denúncia anterior, viável a redução no patamar de 1/5 nesta etapa.

A pena fica, então, definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Cada dia-multa é fixado no valor unitário mínimo, diante da ausência de elementos a evidenciar maior capacidade econômica por parte do réu.

Réu DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não se identifica motivo válido para majoração da pena-base (fl. 123), que fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento, contudo é de se aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto o acusado é primário, não registra Maus antecedentes (fl. 123), bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminosa e se dedique a atividades ilícitas.

Quanto ao montante da diminuição, diante do silêncio da lei, serão adotadas as circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, de forma preponderante, além das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como forma de cumprir o princípio da individualização da pena, decorrente da isonomia, tratando-se de forma igual os iguais, e desigual os desiguais, na medida exata das desigualdades. Não obstante, com a finalidade de afastar a alegação de "bis in idem", conforme decisão também do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (HC 112776/MS), apenas aquelas circunstâncias do artigo 42, da Lei Antidrogas, ou do artigo 59, do Código Penal, não utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena podem ser valoradas para obtenção do quanto de diminuição.

Considerando a prática do delito em concurso de agentes, bem como a variedade - duas espécies - quantidade e a natureza das drogas (66,01g de cocaína e 523,4g de maconha - fls. 22/23), uma delas - cocaína - de elevado poder vulnerante à saúde pública -, a denotar organização, ainda que incipiente, da atividade criminosa, inclusive referendada por denúncia anterior, viável a redução no patamar de 1/5 nesta etapa.

A pena fica, então, definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Cada dia-multa é fixado no valor unitário mínimo, diante da ausência de elementos a evidenciar maior capacidade econômica por parte do réu.

Dadas as peculiaridades do caso concreto, os réus farão jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, a teor do que dispõe o artigo 44, do Código Penal.

Deveras, os réus foram condenados por crime de tráfico privilegiado, que não se equipara a crime hediondo, são primários e sem Maus antecedentes, a pena aplicada não é superior a quatro anos e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Demais disso, a medida mostra-se mais eficaz para sua ressocialização do que a segregação em estabelecimento carcerário, ponderadas todas as particularidades alhures mencionadas.

Assim, com fundamento no § 2º, do referido artigo, excepcionalmente, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, que deverá ser oportunamente fixado

pelo Juízo das Execuções Criminais, e em prestação pecuniária (art. 43, inc. I), equivalente ao pagamento de dois salários-mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, na forma prevista no artigo 45, § 1º, do Código Penal, sem prejuízo da pena de multa.

Pelos mesmos motivos, também excepcionalmente poderão os réus darem início ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, o que faço para: 1) CONDENAR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma da Lei nº 8.072/90, os réus: a) RAFAEL FELIPE DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos da fundamentação, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo; e b) DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos da fundamentação, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo; 2) ABSOLVENDO a ambos da acusação de prática do delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, defiro aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Cobre-se, se o caso, a comunicação a este Juízo acerca da incineração das substâncias entorpecentes apreendidas em decorrência destes autos, bem como a remessa do termo próprio.

Tendo em vista o disposto no artigo 91, inciso II, do Código Penal, no artigo 63, da Lei 11.343/06, e no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, decreto, em favor da União, o perdimento dos valores apreendidos nos autos (fls. 22/23 e 85), eis que evidenciada a respectiva pertinência com o delito de tráfico de drogas. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Unidade Judicial; oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os direitos políticos dos réus, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Por força do parágrafo 9º do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, devendo eventual gratuidade ser avaliada no momento processual oportuno, quando da execução das penas.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à defensora nomeada à fl. 90, no grau máximo previsto para os atos até então praticados nos termos da tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Providencie-se o que mais for necessário.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA